

1501392-76.2021.8.26.0126

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... são elementares do crime de associação para o tráfico, não se confundem com a habitualidade ou reiteração criminosa. 1.6. Inexiste bis in idem em razão do não reconhecimento do crime continuado, pela habitualidade criminosa, e ainda, a condenação pelo delito de associação para o tráfico." (REsp 1501855/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501392-76.2021.8.26.0126

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244119/2021 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 20111440 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2777/21/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2244119 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Réu:

VINICIUS ARIAS DE ALCANTARA e outro

Data da Audiência:

09/06/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 09 de junho de 2022, às 13 horas e 20 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Mário Henrique Gebran Schirmer - Juiz de Direito Auxiliar, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Leandro Rocha Pereira - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, Felipe Alcantara Sabino (videoconferência) e Vinicius Arias de Alcantara (videoconferência), que declararam possuir defensor constituído na pessoa do Dr.(a) Isael Valdes Moscarde, OAB/SP 354.093, presente a este ato, sendo-lhe concedido o prazo de cinco dias para regularizar a representação processual de seus patrocinados. Presentes as testemunhas da acusação, a saber: Evandro Carlos Alexandre, Ricardo Awazu Fidelis Silva; ausente a testemunha Delza Helena Arias de Alcântara, não intimada.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, Evandro Carlos Alexandre e Ricardo Awazu Fidelis Silva, finalmente foram realizados os interrogatórios dos acusados. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Dada a palavra às partes, por elas foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Delza Helena Arias de Alcântara. Ato contínuo, tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: "Homologo a desistência das partes quanto a oitiva da testemunha Delza Helena Arias de Alcântara. No mais, declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação, absolvendo-se os réus pelo delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006, prevalecendo, no mais, os exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu Vinicius e a condenação parcial do corréu Felipe, fixando a pena base no mínimo legal. Segue sentença.

Trata-se de AÇÃO PENAL ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em desfavor de FELIPE ALCANTARA SABINO e VINICIUS ARIAS DE ALCANTARA, já qualificados, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e, ainda, em desfavor de FELIPE a suposta prática do crime do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03.

A denúncia foi deduzida nos seguintes termos:

"Consta do inquérito policial que em data incerta, porém, anteriormente ao dia 08 de setembro de 2021 e até a referida data, FELIPE ALCANTARA SABINO e VINICIUS ARIAS DE ALCANTARA associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o delito de tráfico de drogas. Consta do inquérito policial que, no dia 08 de setembro de 2021, à tarde, na Rua Quatorze, nº 493, Massaguaçu, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba, FELIPE ALCANTARA SABINO e VINICIUS ARIAS DE ALCANTARA, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito 364 (trezentos e sessenta e quatro) papелotes de Cocaína, com peso total de 366,5g, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16/18 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 14/15. Por fim, consta que, nas mesmas condições de tempo e local, porém, em contexto fático diverso, FELIPE ALCANTARA SABINO portava e possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) revólver, calibre .32, marca Taurus, com a numeração suprimida, consoante Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16/18. Segundo restou apurado, os DENUNCIADOS se associaram para o fim de praticarem, ainda que não reiteradamente, o tráfico de drogas e, para tanto, guardavam e tinham em depósito ao menos os entorpecentes acima descritos. Ocorre que policiais militares receberam uma informação via COPOM de que haveria disparos de arma de fogo no Bairro Getuba, rumando para o local indicado. Ao chegarem ao local, a equipe policial avistou os dois DENUNCIADOS que, ao notarem a presença dos agentes, correram na via pública, sendo possível constatar, porém, que o DENUNCIADO FELIPE portava uma arma de fogo pequena, semelhante a um revólver, e que VINICIUS trazia consigo uma sacola verde. Nesse contexto, os DENUNCIADOS, para se esquivarem da abordagem policial, adentraram na residência de sua genitora. Em perseguição, os policiais adentraram na residência e avistaram os DENUNCIADOS sentados na cama, ofegantes e, em vistoria pelo local, foi encontrado debaixo da cama a sacola verde e um revólver desmuniado. Na sacola, foram encontrados 65 (sessenta e cinco) papелotes de Cocaína; no quarto foram localizados 03 (três) rádios comunicadores sem fio e uma base para carregamento, mais 05 (cinco) aparelhos celulares antigos e 02 (dois) aparelhos celulares tipo smartphone. Questionados se havia mais armas, os DENUNCIADOS disseram que não e que haviam enterrado no quintal um cano com mais Cocaína. Diante disso, os policiais se

dirigiram para o quintal e acharam enterrado um cano PVC e dentro continha 299 (duzentos e noventa e nove) papé debates de Cocaína. Em seus interrogatórios policiais, os DENUNCIADOS afirmaram que se encontravam na residência da mãe e que os policiais adentraram no local sem autorização. Afirmaram, ainda, que as drogas não lhes pertenciam, bem como a arma de fogo (fls. 10/11 e 12/13). Tais circunstâncias, a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento e a tentativa de fuga do flagrante evidencia a prática da traficância. Ademais, diante da vasta quantidade de entorpecentes e o encontro de diversos aparelhos celulares e comunicadores, evidencia-se, ainda, a associação para o tráfico, não sendo o envolvimento dos DENUNCIADOS mero concurso de agentes. Quanto ao porte de arma de fogo de uso restrito pelo DENUNCIADO FELIPE, a "denúncia" irradiada via COPOM, a visualização da arma pelos agentes da lei e posterior apreensão do artefato, evidencia a prática do crime (fls. 16/18)." (fls. 10-12).

As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas (fls. 89-93).

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2021, sendo determinada também a quebra do sigilo telefônico dos acusados (fls. 140-142).

Os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 168-169), ressaltando-se ao direito de apresentar teses de mérito no momento adequado.

O recebimento da denúncia foi confirmado, sendo designada data para realização de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 200-202).

Foi produzida a prova oral, com a oitiva das testemunhas, bem como a inquirição dos acusados, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020.

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pugnou pela parcial procedência da denúncia, argumentando que improcedente a imputação em relação ao delito do art. 35, da Lei 11.343/06. Em relação, aos demais delitos, manifestou-se pela procedência, argumentando, especificamente, que caracterizada a autoria de ambos os acusados que em relação ao delito do art. 33, Lei 11.343/06, na medida em que demonstrada o liame subjetivo e a finalidade com no agir.

A defesa dos acusados Vinicius e Felipe postulou pela parcial improcedência da denúncia. Reiterou as alegações do Ministério Público, em relação à imputação do art. 35, da Lei 11.343/06. Argumentou também que devida a absolvição de Vinicius, em razão da confissão de Felipe, pela imputação de tráfico de drogas. Em relação a dosimetria de Felipe, postulou pela fixação da pena base no mínimo legal e a confissão espontânea.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Inexistem alegações a respeito do trâmite processual e, tampouco, há, neste contexto, matéria a se conhecer de ofício, dado que o feito transcorreu regularmente.

Por esta razão, possível o julgamento do mérito.

2. Antes, todavia, são necessários alguns apontamentos a respeito do standard probatório reclamado para a legitimação de uma condenação na seara penal. Afinal, a imposição de quaisquer penalidades pressupõe, para sua validade, não apenas o efetivo exercício de coerção, antes exigindo, também, que o poder estatal esteja assentado em premissas discursivas de legitimação (a respeito ver: FORST, Rainer. Justificação e Crítica - perspectivas de uma teoria crítica da política. São Paulo: Editora Unesp, 2018; ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009). Trata-se, ao fim e ao cabo, da necessidade de justificação do poder, o que é inerente ao próprio conceito de democracia.

Nesse contexto, a imposição de penas exige que o decreto condenatório esteja alicerçado em provas e fundamentos que conduzam a uma conclusão que se coloca além de um patamar de 'dúvida razoável' a respeito da existência e autoria delitivas. Neste sentido é a doutrina de Gustavo Badaró, ao afirmar que, conquanto a atividade probatória ambicione a reconstrução de fatos históricos - os quais, por evidente, não podem ser reproduzidos de maneira idêntica e absoluta -, nas hipóteses de

procedência da pretensão punitiva deverá ser alcançada uma conclusão assentada em um "altíssimo grau de probabilidade" de ocorrência de fatos tais como narrados na denúncia (BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62). Isto se traduz, em síntese, em afirmar que a possibilidade de condenação está à mercê da maior ou menor solidez do contexto probatório que se está inserido, sendo, no entanto, necessário, sempre, um mínimo de lastro probatório para que se possa proferir um decreto condenatório.

Feitas tais considerações gerais a respeito dos níveis probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo ao exame dos elementos de prova existentes nos autos para atestar a comprovação, ou não, da prática dos delitos imputados aos réus.

3. Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade dos delitos está demonstrada, sobretudo pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 29-31), Auto de Constatação Preliminar (fls. 27-28), laudo pericial das drogas apreendidas (fls. 175-177; 178-180), laudos dos celulares apreendidos (fls. 181-197), laudo pericial da arma apreendida (fls. 229-231), fotos (fls. 57-63), Auto de prisão em flagrante (fl. 14), além da prova oral produzida em juízo.

4. Passo à análise da autoria.

Nesse contexto, as testemunhas Evandro e Ricardo (policiais militares) depuseram em harmonia e consonância dos fatos, tendo ratificado os depoimentos prestados durante a fase policial.

A testemunha Ricardo narrou, em síntese, que estava em patrulhamento, com seu companheiro, quando receberam a informação de disparo de arma de fogo, em via pública. Dirigiram-se ao local e ao adentraram a Rua 14, viram os acusados, sendo que o Felipe estava com uma arma e o Vinicius com uma sacola. Em seguida, eles empreenderam fuga e entraram numa residência, ao tempo que os policiais os seguiram. Na sequência, lograram capturas os acusados, em um quarto da referida residência. Embaixo da cama, deste quarto, estavam a sacola com drogas e a arma, vistas anteriormente. Perguntaram sobre mais drogas, sendo que o acusados teriam dito que havia um cano enterrado, com mais entorpecentes. Narrou que ao avistarem os dois acusados na rua era perceptível que estavam juntos, em conluio, e assim que viram a viatura, empreenderam fuga. Disse que viu Felipe com a arma e Vinicius com a sacola e esses pertences são os mesmos que encontraram embaixo da cama. Relatou que estava em viatura policial, no banco da frente, e notou os acusados quando estava a, aproximadamente, 50m deles. Disse que eles correram pela parte lateral da rua e, então, entraram na residência. Narrou que na casa, inicialmente, não havia mais ninguém, mas depois chegaram familiares, embora ninguém dissesse ser morador do local. Não recorda de irmão dos acusados tomando banho no momento da prisão. Esclareceu que ambos os acusados estavam em um quarto quando da apreensão. Afirmou que ambos os policiais localizaram a droga e a arma, as quais, disse, estavam embaixo da cama. Afirmou que, agora, não sabe dizer quem é Felipe e quem é Vinicius, mas sabe dizer que, no momento da abordagem, a arma estava com Felipe. Relatou que ambos confirmaram o local onde estavam as outras drogas. Esclareceu a droga, encontrada em um cano, estava enterrada. Disse que o revólver era calibre 32.

A testemunha Evandro disse não saber de informações a respeito de Felipe e Vinicius com envolvimento com organização criminosa ou associação para o tráfico. Relatou que no dia dos fatos foi encaminhada informação de disparo de arma de fogo e, então, foram até o local. Ao chegarem à próxima da Rua 14 viram os acusados, que empreenderam fuga ao visualizar a viatura, sendo, no momento, possível notar que Felipe estava com uma arma e Vinicius com uma sacola cor verde. Em seguida, perseguiram os acusados até a apreensão de ambos, em um quarto, no qual abaixo da cama havia um revólver e uma sacola com cocaína. Disse que, na sequência, os acusados afirmaram que, no quintal, havia um cano, enterrado, com mais drogas. Afirmou que além das drogas encontradas, também localizaram rádios de comunicação e celulares. Afirmou que, aparentemente, Felipe e Vinicius moravam no local. Disse que notou a mãe dos acusados somente após a abordagem e que a entrada na casa foi ato contínuo da perseguição. Afirmou que era Felipe quem portava a arma e que no

momento da abordagem Felipe e Vinicius se identificaram no local. Esclareceu que, no momento da abordagem, a pessoa que se identificou como Felipe era quem portava a arma de fogo em momento anterior. Disse que, atualmente, não sabe dizer quem é Felipe e quem é Vinicius, pois eles são irmãos e já transcorreu bastante tempo dos fatos. Relatou que quando entraram na via pública em que se iniciou a perseguição estavam com viatura, sendo que, embora não recorde empiricamente, via de regra, o depoente é motorista. Narrou que a perseguição foi inicialmente de carro, mas posterior a pé. Disse que a distância em que visualizaram os acusados foi de 30 a 40m, aproximadamente. Narrou que no momento de visualização e abordagem não viram os acusados vendendo as drogas. Afirmou que, na casa em que ocorreu a abordagem, não lembra se havia alguém tomando banho. Disse que a droga foi encontrada num tubo de PVC, no quintal, enterrado e que a arma era calibre 32, sem munição.

Em seu interrogatório, o acusado Vinicius negou a prática dos delitos e, em resumo, alegou que se trata de flagrante forjado. Disse que mora em Casa Branca e não no Getuba, estando no local em decorrência de compromissos de trabalho anteriores. Disse que estava na casa de sua mãe, quando seu irmão Felipe chegou e não falou nada. Na sequência, a polícia entrou, sem pedir autorização, e os policiais lhe renderam. Narrou que os policiais diziam que seu irmão teria sido visto correndo e, então, procederam com a abordagem. Afirmou que os policiais os separaram para questionamento e, sem razão, em sequência, disseram que drogas as quais desconhece seriam de propriedade dele e de seu irmão. Afirmou que na residência havia mais pessoas, assim como mais policiais e vizinhos nas redondezas.

Em seu interrogatório, o acusado Felipe confessou a prática dos delitos. Disse que estava na via pública, fumando, com um amigo, e ao ver a viatura empreendeu fuga, em direção à casa de sua mãe. Disse que não sabia que seu irmão estava na casa de sua mãe e que seu amigo, que lhe acompanhava quando fumava na rua, fugiu para outro lado. Afirmou que em sua casa, quando da apreensão, tinham familiares. Disse que em seu quarto não havia nada de ilícito, mas que, realmente, tinha uma arma e drogas dentro de sua casa, tendo, inclusive, confessado isso para a polícia. Afirmou que a droga e o revólver eram seus e não de seu irmão. Alegou que estava com a droga porque estava passando por necessidade.

5. Diante deste cenário, entendo que ficaram comprovadas autorias e materialidades do delito de tráfico.

5.1. No ponto, ressalto, em primeiro lugar, que os policiais militares narraram com clareza e de forma detalhada como se deram os fatos. Além disso, não há nos autos indícios de que eles tenham se manifestado de maneira maliciosa e temerária, imputando falsamente à prática criminosa aos acusados. Ao contrário, o que se observa é que os agentes públicos asseveraram com precisão o desdobramento dos fatos, imprimindo certeza e seriedade em suas narrativas.

Neste contexto, a jurisprudência, há muito, já firmou entendimento de que o testemunho dos policiais tem valor idêntico ao de outras pessoas quaisquer que não possuam qualquer interesse no julgamento. Por todos, veja-se o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

E, também, do STJ:

"3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos

agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)".

5.2. Nesse cenário, observe-se que os relatos confirmaram a pretensão punitiva descrita na inicial acusatória.

No ponto, é imperioso notar que a versão apresentada pelos policiais é coesa, verossímil e se manteve íntegra ao longo de toda a instrução. Ao contrário, as narrativas ofertadas pelos acusados apresentam diversas obscuridades e contradições, sendo, ao fim e ao cabo, inverossímeis, na medida em que se limitam a impugnar a própria ação dos agentes policiais ou apresentar teses de ausência de autoria de Vinicius, sem, contudo, fornecer qualquer elemento concreto, senão as próprias impugnações.

Neste contexto, é sintomática a alteração de versão apresentada por Felipe. Em seu interrogatório em fase de inquérito, o acusado se limita a negar a prática do crime, imputando a existência de suposta flagrante forjado aos policiais. Em específico, não menciona que estava na rua, em momento anterior – tal como faz em seu depoimento judicial – ou a propriedade da droga e das armas. Em contrapartida, os depoimentos prestados pelos policiais são bastante firmes, até mesmo com alguns detalhes, e absolutamente harmônicos e coerentes.

Daí a razão pela qual, in casu, é devido conceder prevalência às versões apresentadas pelos agentes públicos, uma vez que mais verossímeis – aproximando-se, pois, de maneira mais adequada a reconstrução dos fatos transcorridos nas imputações apresentadas – e apresentada por pessoas imparciais e sem qualquer interesse no julgamento.

5.3. Diante do cenário probatório, é possível concluir, para além de dúvida razoável, que durante patrulhamento de rotina os policiais observaram os acusados, os quais empreenderam fuga tão logo notaram a viatura policial. Em perseguição, os policiais encontraram com os acusados uma porção de drogas e, posteriormente, os réus confirmaram que guardavam mais drogas consigo, as quais também foram apreendidas. Ainda, durante a ação policial, foi possível constatar que o acusado Felipe portava um revólver calibre 32, com capacidade para realização de disparos atestada, posteriormente por perícia (fls. 229-231).

6. Por esta razão, passa à análise do tipo penal.

6.1. Como se sabe, para a caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não se faz necessário que o acusado seja surpreendido no próprio ato da mercancia ilícita. Isto porque o tipo penal exposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é um crime de núcleo misto e alternativo, para o qual basta a configuração de uma das condutas nucleares do tipo para que esteja comprovada a prática penal.

Nesse sentido, observe-se a redação do art. 33, da Lei 11.343/06: "Art.33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (grifo nosso).

In casu, a conduta dos agentes se ajusta aos verbos descritos no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, consumando-se o delito com a prática de qualquer uma das hipóteses previstas, na medida em que as condutas se enquadram na forma descritiva dos tipos penais de: "trazer consigo", "guardar" e "transportar".

Nesse sentido, nota-se que há liame subjetivo entre os agentes e a pluralidade de condutas ambiciona uma finalidade comum – conforme especificamente presente no depoimento da testemunha André –, razão pela qual, na forma do art. 29, do CP – o qual adota o conceito de 'fato global' – o acusado deve responder pelo resultado final dos atos para os quais cooperou (in verbis: "Art. 29 Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade").

Por esta razão, comprovada a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

6.1.1. Ainda no ponto, impossível a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Em relação ao acusado Vinicius a cláusula de tráfico privilegiado é obstada, uma vez que o réu apresenta condenação penal com trânsito em julgado (fls. 77-78), não estando, pois, caracterizado o requisito da primariedade.

Em relação ao acusado Felipe é indevida a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em vista das circunstâncias do caso em análise as quais provem alicerces suficientes para demonstrar que o requisito de ausência de dedicação a atividade criminosa não está caracterizado. Note-se que, embora o acusado seja primário (fl. 80), apresenta diversas passagens infracionais, dentre elas pela prática do ato infracional análogo ao tráfico de drogas (fl. 81). Nesse sentido, a despeito do entendimento deste juízo ser, via de regra, pela possibilidade da aplicação da minorante, aos casos em que o acusado praticou atos infracionais, haja vista que as condutas foram praticadas em contexto de inimputabilidade (art. 27, do CP), as circunstâncias do caso em análise evidenciam que o réu se dedicava a atividades criminosas.

Neste contexto, não se olvide que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a prática de atos infracionais anteriores, embora não necessariamente induza a rejeição da minorante, é fator que pode ser considerado pelo juízo para o afastamento da cláusula de privilegio. Por todos:

“A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, como ocorre na espécie.” (AgRg no HC n. 733.918/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022)

In casu, está demonstrado que o acusado realizava efetivamente o tráfico de drogas, em quantidades significativas, conforme acima exposto.

Por todo o exposto, impossível a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em relação ao acusado Felipe.

6.2. A norma penal prevista no art. 35, da Lei 11.343/06, expõe como típica a conduta de “Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei”.

Conquanto o texto normativo determine como típica a conduta, independente de reiteração, a jurisprudência tem entendimento consolidado no sentido de que a 'estabilidade e permanência' são imprescindíveis. Por todos, veja-se:

“1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes.” (RHC 108.003/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

No ponto, a jurisprudência – de maneira acertada – destaca, ainda, que os requisitos de 'estabilidade e permanência', exigidos para a configuração do delito do art. 35, da Lei 11.343/06, são distintos do elemento de reiteração – este sim dispensado.

“1.5. A estabilidade e permanência, que são elementares do crime de associação para o tráfico, não se confundem com a habitualidade ou reiteração criminosa. 1.6. Inexiste bis in idem em razão do não reconhecimento do crime continuado, pela habitualidade criminosa, e ainda, a condenação pelo delito de associação para o tráfico.” (REsp 1501855/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017).

Nesse sentido, o que se verifica é que para a configuração do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, faz-se necessário demonstrar que a associação para o tráfico preenche os requisitos de 'estabilidade e permanência' – requisitos que, note-se, também são exigidos para a configuração do crime do art. 288, do CP (associação criminosa) –, prescindindo, no entanto, da comprovação de reiteração. Em outras palavras: a conduta do art. 35, da Lei 11.343/06, é típica, ainda que cometida uma única vez (ausência de reiteração), desde que demonstrada a 'estabilidade e permanência'.

No ponto, destaque-se que a exigência de estabilidade e permanência não ofende ao princípio da legalidade. Ao contrário, somente afirma uma diferença normativa e ontológica entre os art. 29, do CP (concurso de pessoas) e o tipo do art. 35, da Lei 11.343/06 (ou, para tais fins, também do art. 288, do CP). Afinal, há uma distinção essencial – reconhecida pelo legislador, sendo, portanto, também normativa – entre o cometimento de um delito juntamente com outro agente (art. 29, do CP – concurso de pessoas) e a associação para o cometimento de delitos (art. 35, da Lei 11.343/06 e art. 288, do CP). Esta distinção é, justamente, a 'estabilidade e permanência'.

In casu, a despeito da fundada suspeita de que os acusados realizavam o tráfico de drogas mediante um esquema de estabilidade e permanência – o que, frise-se, é distinto de reiteração –, é certo que tal situação não restou provada para além de dúvida razoável.

Note-se que, embora tenha sido deferida a quebra dos sigilos telefônicos dos aparelhos apreendidos, não foi possível acesso a mensagens que comprove a existência de estabilidade e permanência dos acusados para o tráfico de drogas. Nesse sentido, se muito, existiria uma suspeita a respeito da existência de associação para o tráfico, mas o standard probatório necessário não foi atingido. Ademais, considerando a manifestação do Ministério Público e a primazia do sistema acusatório, ressalvadas situações teratológicas, não é devido ao juízo proceder a condenação, quando a absolvição é requerida pelo Parquet.

6.3. Em relação ao porte de arma com numeração suprimida, o art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, determina como delituosa a conduta de: “Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: § 1º Nas mesmas penas incorre quem: IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado”. Trata-se de delito de mera conduta e perigo abstrato e que, portanto, se consuma com o simples fato de o acusado ter em sua posse, em casa ou local de trabalho, armamento ou munição de uso permitido, que apto à realização de disparos. No caso em análise, o crime restou comprovado, atraindo a incidência do art. 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento, dado que os relatos apresentados nos autos comprovam que o acusado Felipe, quando da ação policial, portava um revólver calibre .32, com numeração suprimida e apto a realização de disparos (fls. 229-231).

Nesse contexto, tratando-se de delitos de mera conduta, perigo abstrato e estando comprovado que o réu, efetivamente, portava o artefato em contrariedade a determinação legal, está demonstrada a tipicidade da ação.

7. A respeito dos demais elementos dos injustos penais, observa-se que os réus são imputáveis, têm a consciência da ilicitude de suas ações, lhes era exigível conduta diversa e não agiam amparado por causa excludente de ilicitude, devendo, então, responder pelas ações praticadas, dado que todos os elementos da estrutura analítica dos delitos estão presentes.

8. Ante o exposto, restou claramente demonstrado que os acusados FELIPE ALCANTARA SABINO e VINICIUS ARIAS DE ALCANTARA realizaram condutas típicas e antijurídicas, subsumíveis aos tipos penais indicados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e o acusado FELIPE ALCANTARA SABINO, também praticou condutas típicas e antijurídicas, subsumíveis aos tipos penais indicados no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03.

9. Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68, do CP.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, apresenta pena abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa. O delito tipificado no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, comina pena em abstrato de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.

9.1. Na análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CP, não foi possível valorar a conduta social, o comportamento da vítima, a personalidade dos agentes, em razão da ausência de elementos informativos a respeito de tais vetores. Ainda, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

A culpabilidade de Vinicius é neutra. A culpabilidade de Felipe deve ser ponderada em seu favor, haja vista sua menoridade relativa quando da realização do delito. Isto porque, in casu, verifica-se a presença de duas atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea). Por esta razão, nos termos do art. 68, do CP, considerando o sistema escalonado de dosimetria da pena e a existência de duas atenuantes, a circunstâncias do art. 65, I, do CP, será valorada neste momento, dado que o próprio legislador entende como menos reprovável a conduta daqueles que ainda não completaram 21 (vinte e um) anos quando dos fatos.

O acusado Felipe é primário (fls. 80). O acusado Vinicius apresenta duas condenações penais com trânsito em julgado (fls. 77-78). Por este motivo, em vista do sistema escalonado de dosimetria da pena, nos termos do art. 68, do CP, uma das condenações será utilizada a título de Maus antecedentes.

Ainda no contexto da primeira fase, o art. 42 da Lei 11.343/06, estabelece, como circunstâncias preponderantes no contexto da análise da primeira fase da dosimetria, a ponderação da natureza e quantidade de drogas. In casu, a quantidade de drogas, embora não seja desprezível, deve ser tida como neutra, uma vez que dentro dos patamares verificados na prática deste juízo. Igualmente, a natureza da droga deve ser analisada negativamente, uma vez que a substância em análise (cocaína) é capaz de gerar gravíssimos danos à saúde e implicar em forte dependência química, conforme consenso na comunidade científica.

Desta maneira, conforme o exposto acima, fixo as penas bases em: (i) ao acusado Felipe: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em relação ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em decorrência da prática do delito do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03; (ii) ao acusado Vinicius: 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em relação ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

9.2. Passo à segunda fase da dosimetria. Neste momento, analisam-se as circunstâncias agravantes e atenuantes.

No caso, o acusado Vinicius é reincidente, conforme acima exposto, em razão da condenação nos autos 0011005-39.2017.8.26.0126 (art. 33, da Lei de Drogas) e inexistente atenuante em seu favor. Por esta razão, a pena deve ser exasperada em 1/6 (um sexto).

O acusado Felipe não apresenta nenhuma agravante que pese contra si e faz jus ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, na forma do art. 65, III, d, do CP. Contudo, a pena mantém-se no mínimo legal, em razão da impossibilidade de fixação aquém do patamar legalmente previsto na segunda fase, nos termos da Súmula 231, do STJ.

Desta maneira, conforme o exposto acima, fixo as penas intermediárias em: (i) ao acusado Felipe: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em relação ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em decorrência da prática do delito do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03; (ii) ao acusado Vinicius: 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezesse) dias-multa, em relação ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

9.3. Na terceira fase da dosimetria, estão ausentes causas de aumento ou diminuição.

Pelo exposto, as penas definitivas ficam em: (i) ao acusado Felipe: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em relação ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em decorrência

da prática do delito do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03; (ii) ao acusado Vinicius: 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, em relação ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 10. A respeito do concurso de crimes, tendo em vista que os delitos cometidos por Felipe são autônomos, realizados mediante condutas, dolos e momentos consumativos distintos, devido o reconhecimento do concurso material, na forma do art. 69, do CP, com a somatória das penas.

Por esta razão, as sanções definitivas totalizam: (i) ao acusado Felipe: 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03; (ii) ao acusado Vinicius: 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, em relação ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

11. Tendo em vista o quantum de pena aplicado e os antecedentes penais dos acusados, nos termos do art. 33, §2º, do CP, fixo regime inicial FECHADO ao acusado Vinicius e regime inicial SEMIABERTO ao acusado Felipe.

O valor do dia multa será calculado no valor unitário mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/2006), haja vista a inexistência de provas a respeito de riqueza, e deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, desde a data da infração.

12. O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese, notadamente para o fato delituoso em comento, relativo ao bom comportamento carcerário (art. 112 da LEP) que, in casu, não é do conhecimento profundo deste Juízo.

13. Em vista do quantum de pena aplicado, incabível a aplicação dos art. 44 e art. 77, do CP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

(i) com fundamento no art. 386, III, do CPP, ABSOLVER os acusados FELIPE ALCANTARA SABINO e VINICIUS ARIAS DE ALCANTARA, já qualificados, pela suposta prática do delito previsto no art. 35, da Lei 11.343/06;

(ii) com fundamento no art. 387, do CPP, CONDENAR os acusados FELIPE ALCANTARA SABINO e VINICIUS ARIAS DE ALCANTARA pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e ainda o acusado FELIPE ALCANTARA SABINO, pela prática do crime do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, aplicando-lhes as sanções de:

ao acusado FELIPE ALCANTARA SABINO: 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com juros e correção pela tabela do TJ-SP, a contar da data dos fatos, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03;

ao acusado VINICIUS ARIAS DE ALCANTARA: 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 817 (oitocentos e dezessete), dias-multa com juros e correção pela tabela do TJ-SP, a contar da data dos fatos, em relação ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Custas pelos acusados, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade que lhes sejam deferidas.

Tendo em vista que a sentença penal não tem por consequência alterar de maneira automática e imediata a condição processual dos acusados, deixo de proceder com alterações a respeito das medidas cautelares em relação aos acusados.

Nos termos do art. 50-A, da Lei 11.343/2006, DETERMINO a incineração das drogas apreendidas, sendo tomadas as devidas cautelas legais.

A respeito dos bens, nos termos do art. 61, da Lei 11.343/06, determino o perdimento dos valores apreendidos, em favor da União.

Serve a presente decisão como ofício/mandado/intimação.

Expeçam-se as guias e certidões necessárias.

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

Após o trânsito em julgado:

- i. Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
 - ii. Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal;
 - iii. Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.
 - iv. Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu;
 - v. Expeça-se guia de execução penal.
- Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Pelo Ministério Público foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença para acusação. Pela defesa foi dito que DESEJA RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória imediatamente. Abra-se vista a defesa para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Mário Henrique Gebran Schirmer
Juiz de Direito Auxiliar

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/EsuVy-835qVLhyfQIjv_JBAB2VzjekuEY78GfP4BcaqGKw?e=ThVMfp